



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação nº 0027123-08.2015.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
Apelante: Diogo Lopes Dias do Nascimento
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto nº 9192

Registro: 2017.0000616347

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0027123-08.2015.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante DIOGO LOPES DIAS DO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as preliminares, deram parcial provimento ao recurso para conceder ao apelante a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos, com as condições previstas no art. 78, § 2º, letras "b" e "c", do Código Penal, mantida, nos mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), GUILHERME G. STRENGER E MARIA TEREZA DO AMARAL.

São Paulo, 16 de agosto de 2017.

Alexandre Almeida
RELATOR
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação nº 0027123-08.2015.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
Apelante: Diogo Lopes Dias do Nascimento
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto nº 9192

***Violência doméstica – Lesão corporal –**
 Suspensão condicional do processo –
 Impedimento – Art. 41 da Lei nº 11.340/06 –
 Nulidade – Inocorrência – Preliminar rejeitada;
Apelação – Ausência de transcrição dos
 depoimentos colhidos em audiência – Mídia
 digital disponível nos autos para as partes –
 Desnecessidade – Exegese do art. 405, §§ 1º e 2º,
 do Código de Processo Penal – Nulidade –
 Inocorrência – Preliminar rejeitada;
Violência doméstica – Lesão corporal –
 Testemunha referida – Indeferimento – Nulidade
 – Inocorrência – Exegese do art. 209, do Código
 de Processo Penal – Preliminar rejeitada;
Violência doméstica – Lesão corporal –
 Agressão contra ex-namorada – Materialidade
 demonstrada – Lesão compatível com a conduta
 atribuída ao réu – Palavra da vítima – Prova
 determinante em crimes dessa natureza –
 Condenação mantida;
Violência doméstica – Lesão corporal –
 Violência doméstica – Legítima defesa – Não
 comprovação – Condenação mantida;
Violência doméstica – Lesão corporal – Pena
 correta – Substituição da pena privativa de
 liberdade por restritiva de direitos – Expressa
 vedação legal – Recurso provido em parte para
 conceder o **sursis**.*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação nº 0027123-08.2015.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
Apelante: Diogo Lopes Dias do Nascimento
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto nº 9192

Vistos.

DIOGO LOPES DIAS DO NASCIMENTO,

qualificado nos autos, foi denunciado, processado e ao final condenado por r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. André Gustavo Cividanes Furlan, da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo, como incurso no art. 129, §9º, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 3 meses de detenção em regime aberto (fls. 125/126).

Isso porque, no dia 4 de outubro de 2015, por volta das 18h30min, na Praça Geovane Breda, bairro Assunção, na cidade de São Bernardo do Campo, ofendeu a integridade física de sua ex-namorada Izamara Maria da Silva, desferindo um soco em seu rosto, que causou nela lesões corporais de natureza leve.

Inconformada apela a Defesa arguindo preliminar de nulidade do processo pela falta de proposta de suspensão do processo, nos termos do art. 89 da Lei nº 9.099/95 e por cerceamento de defesa, já que não houve transcrição dos depoimentos gravados em mídia digital e porque foi negado pedido para oitiva de testemunhas referidas pela vítima. No mérito, busca a absolvição do acusado sob o argumento de que a prova é frágil e insuficiente para embasar o decreto condenatório, inclusive



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação nº 0027123-08.2015.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
Apelante: Diogo Lopes Dias do Nascimento
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto nº 9192

porque agiu em legítima defesa. Subsidiariamente, pede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a concessão da suspensão condicional da pena, ou ainda o reconhecimento da figura privilegiada prevista no art. 129, § 4º, do Código Penal, com fixação de regime mais brando (fls. 134/152).

Recebido o recurso (fls. 126), vieram aos autos as contrarrazões (fls. 156/159).

Bem processado o apelo, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso (fls. 163/171).

É o relatório.

Cuida-se de recurso interposto por Diogo Lopes Dias do Nascimento contra a r. sentença de fls. 125/126 que julgou procedente a ação penal e o condenou, por infração ao art. 129, § 9º, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 3 meses de detenção em regime aberto.

E, na análise dos argumentos trazidos com o recurso, cumpre inicialmente afastar a preliminar de nulidade do sentença pela falta de proposta de suspensão do processo.

Isso porque a conduta do apelante veio enquadrada no art. 41, da Lei nº 11.340/06, que expressamente impede a aplicação dos benefícios da Lei nº 9.099/95 nas hipóteses de violência doméstica e familiar, de maneira que não era mesmo cabível a suspensão condicional do processo prevista no art. 89, desse último diploma.

Confira-se, a propósito: **“VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ARTIGO 41 DA LEI Nº 11.340/06 – ALCANCE. O**



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 Apelação nº 0027123-08.2015.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
 Apelante: Diogo Lopes Dias do Nascimento
 Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
 Voto nº 9192

preceito do artigo 41 da Lei nº 11.340/06 alcança toda e qualquer prática delituosa contra a mulher, até mesmo quando consubstancia contravenção penal, como é a relativa a vias de fato. VIOLENCIA DOMÉSTICA – ARTIGO 41 DA LEI Nº 11.340/06 – AFASTAMENTO DA LEI Nº 9.099/95 – CONSTITUCIONALIDADE. Ante a opção político-normativa prevista no artigo 98, inciso I, e a proteção versada no artigo 226, § 8º, ambos da Constituição Federal, surge harmônico com esta última o afastamento peremptório da Lei nº 9.099/95 – mediante o artigo 41 da Lei nº 11.340/06 – no processo-crime a revelar violência contra a mulher.” (STJ, HC 106.212, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Julgado em 24/03/2011);

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. VIOLENCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESO. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.099/95. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). PRECEDENTE. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade do art. 41 da Lei n. 11.340/2006, que afasta a aplicação da Lei n. 9.099/1995 aos processos referentes a crimes de violência contra a mulher. 2. Ordem denegada”.
 (HC nº 110.113, Rel. Min. Carmen Lúcia, Julgado em 20/03/12);

“A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, analisando o tema em voga, vem manifestando seu entendimento jurisprudencial no sentido da configuração de violência doméstica contra a mulher, ensejando a aplicação da Lei nº 11.340/06, à agressão cometida por ex-namorado. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 Apelação nº 0027123-08.2015.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
 Apelante: Diogo Lopes Dias do Nascimento
 Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
 Voto nº 9192

Justiça firmou-se no sentido da inaplicabilidade da Lei n.º 9.099/95 aos crimes praticados com violência doméstica ou familiar, em razão do disposto no art. 41 da Lei n.º 11.340/06. In casu, por expressa vedação legal, não pode ser concedida a suspensão condicional do processo. 3. Ordem denegada” (STJ, HC 182.411/RS, Rel. Min. Adilson Vieira Macabu (Des. Conv. Do TJ/RJ), Quinta Turma, Julgado em 14/08/2012);

E ainda: **“HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESO. LEI MARIA DA PENHA, INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.099/95. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. I – O art. 41 da Lei 11.340/06 – Lei Maria da Penha – dispõe que, aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independente da pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099/95, o que acarreta a impossibilidade de aplicação dos institutos despenalizadores nesta previstos, quais sejam, acordo civil, transação penal e suspensão condicional do processo”**. (HC 180.821/MS, Rel. Min. Gilson Dipp – Quinta Turma, Julgado em 04/04/11).

Assim, como é incabível a proposta de suspensão condicional do processo, não há nulidade a ser reconhecida.

Tampouco ocorreu cerceamento de defesa pela ausência de transcrição dos depoimentos colhidos em audiência, já que é absolutamente desnecessária, considerando que o DVD contendo a prova oral colhida está juntado aos autos e sempre esteve disponível para as partes.

Aliás, o art. 405, §§ 1º e 2º, do Código de



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação nº 0027123-08.2015.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
Apelante: Diogo Lopes Dias do Nascimento
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto nº 9192

Processo Penal expressamente dispensa a transcrição do conteúdo da mídia, razão pela qual não se vê qualquer prejuízo para o apelante.

Por fim, não acarreta nulidade o indeferimento do pedido de conversão do julgamento em diligência para oitiva de testemunhas referidas pela vítima.

Isso porque, o juiz, que é o destinatário da prova, é quem deve aferir a conveniência e necessidade da oitiva de alguma pessoa referida, desde que entenda imprescindível ao esclarecimento dos fatos. Portanto, como o art. 209, do Código de Processo Penal atribui ao magistrado a faculdade de ouvir outras testemunhas além das arroladas – e aquelas referidas quando entender conveniente (§ 1º) – não há que se falar em nulidade.

Confira-se, a propósito, o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci, para quem no caso de testemunhas referidas ***“...o critério de deferimento é, exclusivamente, do magistrado. Entretanto, quando alguma testemunha arrolada pela parte fizer expressa referência a pessoa não constante no rol das partes, nem tampouco nos autos do inquérito, é preciso que o magistrado tenha sensibilidade suficiente para avaliar a conveniência e a necessidade de ouvi-la. A inquirição descontrolada de várias pessoas, somente porque foram citadas por outras, produz excesso de prova, conturbando a instrução e provocando o inconveniente de obrigar o julgador ou o tribunal a ler volumes inteiramente inúteis para o desfecho da causa...”*** (Código de Processo Penal Comentado, Editora Revista dos Tribunais, 10ª edição, pag. 498).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação nº 0027123-08.2015.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
Apelante: Diogo Lopes Dias do Nascimento
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto nº 9192

Assim, como o Magistrado não se convenceu dessa necessidade, impossível reconhecer a nulidade no indeferimento do pedido, ou mesmo acolher a pretensão de ver convertido o julgamento em diligência.

Rejeitadas as preliminares, no mérito a absolvição era mesmo impossível.

A materialidade do delito está comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito de fls. 17, que constatou a lesão corporal suportada pela ofendida – ferimento contuso da mucosa gengival superior direita – enquanto a autoria acabou demonstrada pela prova colhida nos autos.

De fato, ao ser interrogado perante a autoridade policial o réu admitiu que viu a ex-namorada na rua e como ela passou a provocá-lo – cumprimentando outros homens – a chamou para conversar, ocasião em que ela o xingou e empurrou. Declarou, então, que apenas revidou o empurrão e negou que tivesse praticado agressão física contra ela (fls. 28).

Entretanto, acabou desmentido e incriminado pela vítima, que contou que o réu não aceitava o fim do relacionamento amoroso e a chamou para conversar. Entretanto, como se recusou, o réu passou a xingá-la, até que desferiu um soco em sua boca (fls. 9/10).

Mas não é só, pois em juízo, agora sob as garantias do contraditório, onde acusado voltou a dizer que a ofendida passou a provocá-lo, motivo pela qual a chamou para conversar, mas foi empurrado e apenas se defendeu (mídia digital), tem-se que a prova tornou



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação nº 0027123-08.2015.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
Apelante: Diogo Lopes Dias do Nascimento
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto nº 9192

definitiva sua responsabilidade.

Isso porque, a vítima, em declarações semelhantes àquelas prestadas na fase policial, reafirmou que tinha um relacionamento com o réu, que a chamou pra conversar, mas como se recusou ele desferiu um soco em seu rosto (mídia digital).

Ora, nos crimes de violência doméstica, onde normalmente não existem testemunhas presenciais, a palavra da vítima ganha especial relevância, especialmente se há prova da materialidade e nada sugere que tudo tenha passado de invenção ou intenção de prejudicar o acusado.

Bem por isso, se o laudo indica que houve lesão compatível com o tipo de agressão noticiada pela vítima – ferimento contuso da mucosa gengival superior direita (fls. 17) – na total ausência de prova de que tudo não passou de simples vingança, como quis fazer crer o acusado, a condenação era mesmo de rigor.

Tampouco a legítima defesa invocada pelo réu ficou demonstrada. Afinal, nada indica que a vítima tenha investido contra o acusado, ao contrário, os indícios trazidos com o inquérito e reproduzidos em juízo evidenciaram que ele ficou alterado e atacou de forma violenta e sem motivo aparente sua ex-namorada, causando nela lesões corporais de natureza leve.

Por fim, impossível o reconhecimento da figura prevista no art. 129, § 4º, do Código Penal, pois não há comprovação de que o crime tivesse sido cometido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de relevante emoção, logo em seguida à injusta



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação nº 0027123-08.2015.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
Apelante: Diogo Lopes Dias do Nascimento
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto nº 9192

provocação da vítima.

Com isso, uma vez que a prova trazida durante o contraditório confirmou a certeza da agressão do acusado contra a ofendida, a conclusão condenatória foi correta, restando analisar a pena imposta.

Nesse mister, o que se percebe é que a pena base foi dosada com critério, no mínimo legal, e não sofreu alterações, a despeito da atenuante da menoridade relativa, que não poderia trazê-la abaixo desse patamar (Súmula nº 231, do Col. Superior Tribunal de Justiça). Observe-se, de qualquer forma, que não houve denúncia ou condenação pelo delito de ameaça.

No mais, foi estabelecido regime aberto e a pena privativa de liberdade não poderia ser substituída por restritiva de direitos, por expressa vedação contida no art. 17, da Lei nº 11.340/36, já que o delito foi praticado com violência contra a mulher.

Por fim, como a Defesa postulou a concessão do **sursis** (a despeito de ser questionável o fato de ser mais favorável ao réu), estando presentes os requisitos do art. 77, do Código Penal, fica deferido o benefício pelo prazo de 2 anos, com a condição de, no primeiro ano cumprir as condições previstas no art. 78, § 2º, letras "b" e "c", do mesmo diploma legal.

Em suma, o parcial provimento do recurso é medida que se impõe à correta solução do caso em questão.

Diante do exposto, **rejeitadas as preliminares,**
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para conceder ao



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação nº 0027123-08.2015.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
Apelante: Diogo Lopes Dias do Nascimento
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto nº 9192

apelante a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos, com as condições previstas no art. 78, § 2º, letras "b" e "c", do Código Penal, mantida, nos mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Custas na forma da lei.

ALEXANDRE Carvalho e Silva de **ALMEIDA**
RELATOR